2차적저작물로의 변형과 공정이용인 변형의 차이**

- 표현형식의 변형과 이용목적의 변형 -

박 준 우*

≪ 목 차 ≫

I. 서론
II. 미국 연방저작권법의 2차적저작물작성권과 공정이용
  1. 2차적저작물작성권 규정
  2. 공정이용 규정
III. '변형적 이용'의 개념
  1. Leval 판사의 논문
  2. 연방대법원과 연방항소법원의 판결
  3. '2차적저작물작성으로서의 변형'과의 관계
IV. 미국 연방법원의 기준: '표현형식의 변형'과 '이용목적의 변형'의 구별
V. '표현된 사상 또는 감정의 변형' 기준의 제안
VI. 결론

I. 서론

현재 국회에는 공정이용법리의 도입을 위한 저작권법의 개정안이[1] 위원회 심사단계에 있다.[2] 또한 한미 FTA의 이행법안에도 공

* 서강대학교 법학전문대학원 부교수. 법학박사.(메일주소)
** 이 연구는 2009년도 서강대학교 교내연구비 지원에 의하여 이루어졌음 (200910032.01).

www.kci.go.kr

정이용규정이 포함되어 있다.[3] 공정이용법리의 도입에는 반대견해도 있다.[4] 반면 공정이용법리를 우리법의 해석에 참고하여야 한다는 견해나[5] 공정이용법리를 한국 저작권법에 도입할 경우의 입법방식을 논의한 논문도 있다.[6] 국제사회에서 미국의 문화산업이 차지하는 비중과 한국의 문화산업이 미국에 진출할 가능성을 고려하면 한국 저작권법에 저작권의 효력제한규정으로서 공정이용법리를 도입하지 아니하더라도 미국의 공정이용법리에 관한 구체적인 쟁점과 논의에 관하여 미리 연구할 필요는 충분히 있다고 본다. 공정이용법리와 관련된 쟁점 중 가장 큰 것은 명확한 가이드라인의 부재이다. 또한 대륙법 국가에서 이를 도입할 경우 저작인격권에 대한 적용여부와 적용기준도 쟁점이 될 수 있다. 그러나 이 논문에서는 공정이용과 2차적저작물작성권 사이의 경계의 문제를 다루고자 한다.

공정이용이 문제되는 많은 경우에 실질적으로 피고작품은 원고작품의 2차적저작물일 것이다.[7] 따라서 피고의 원고작품의 이용이

1) 저작권법 일부개정법률안(변재일의원 대표발의), 의안번호: 2888, 발의연월일: 2008.12.5.

2) 국회 의안정보시스템<http://likms.assembly.go.kr/bill/jsp/BillDetail.jsp?bill_id=PRC_W0I8V1S2Q0T5A1M7I1C0C1B9B4U6Q6>(2009.10.20 확인.).

3) 우지숙, “UCC 창작물에 대한 저작권법 적용의 쟁점 및 미국 패러디 관련 판례의 시사점: 변형적 이용(transformative use) 개념의 도입을 제안함”, 「계간저작권」 제21권 제3호, 저작권위원회, 2008, 99쪽.

4) 위의 논문, 99-100쪽(공정이용의 기준이 불명확한 점과 판례법 국가인 미국의 이론을 대륙법 국가인 한국이 잘 운영할 수 있을지의 여부를 의문시하며 포괄적인 공정이용규정의 도입보다는 개별적인 저작권의 효력제한규정의 이용을 주장.); 김원오, “패러디 항변을 둘러싼 저작권법상 쟁점과 과제”, 「안암법학」 제14호, 안암법학회, 2002, 349쪽(공정이용의 포괄규정이 남용될 경우 저작권자의 권리를 지나치게 제한하거나 저작권 제한 규정의 체제를 전면적으로 뒤흔들 우려가 있음을 지적).

5) 함석천, “패러디, 지적재산권과 표현의 자유”, 「저스티스」 통권 제91호, 한국법학회, 2006, 78쪽.

6) 이대희, “저작권법상의 공정이용의 법리에 관한 비교법적 연구”, 「경영법률」 제10권, 한국경영법률학회, 2000, 360쪽(공정이용의 네 가지 고려사항 이외에도 선의의 존재여부, 산업계의 관행 등의 요소도 법원이 고려하여야 한다고 주장.).

www.kci.go.kr

공정이용에 해당하는지의 여부를 판단할 때에는 공정이용 판단시의 고려요소 중 첫 번째와 네 번째 요소가 중요하다.[8)]

한국 저작권법은 "저작자는 그의 저작물을 원저작물로 하는 2차적저작물을 작성하여 이용할 권리를 가진다."고 규정하고(제22조) '2차적저작물'을 "원저작물을 번역·편곡·변형·각색·영상제작 그 밖의 방법으로 작성한 창작물"로 정의하고 있다(제5조 제1항).

2차적저작물로 인정되기 위하여는 '원저작물과의 실질적 유사성(substantial similarity)'과 '원저작물에 대한 실질적 개변(substantial variation)'이 모두 인정되어야 한다.[9)] 즉, 원저작물과의 실질적 유사성이 인정되지 아니하면 2차적저작물이 아닌 별개의 독립된 저작물이며, 실질적 개변이 없으면 2차적저작물이 아닌 원저작물의 복제물에 불과하다.[10)] 그러므로 피고작품의 2차적저작물의 침해여부가 쟁점인 판례에서 피고작품은 원고저작물의 복제물(실질적 개변이 없는 경우), 2차적저작물(실질적 개변과 실질적 유사성이 있는 경우), 별개의 저작물(실질적 유사성이 없는 경우)의 3가지 중 하나로 판단될 것이다.[11)]

한국과 미국의 저작권법은 모두 2차적저작물의 작성행위 중 하나로서 '변형(transform)'을 규정하였는데, 공정이용 판단시의 첫

---

7) "Since fair use typically involves the incorporation of some portion of a previously protected work, the merits of a fair use defense will be judged in light of the right to make a derivative work." Ruth Okediji, *Givers, Takes, and Other Kinds of Users: A Fair Use Doctrine for Cyberspace*, 53 Fla. L. Rev. 107, 126 (2001).

8) 공정이용 판단시의 첫 번째 요소와 네 번째 요소를 고려할 때의 핵심은 피고가 원고작품에 부가한 변형이 원고의 2차적저작물의 작성으로서 금지되어야 하는 변형인지 아니면 공정이용으로 인정될 수 있는 변형인지의 여부일 것이다. "Is this a true parody, or is it a derivative work that should be subject to the author's control?" Paul Goldstein, *Fair Use in Context*, 31 Colum. J.L. & Arts 433, 440 (2008). 공정이용 판단시의 첫 번째와 네 번째 요소에 관하여는 이 논문의 II.2.의 내용 참조.

9) 오승종, 「저작권법」, 박영사, 2007, 146-147쪽.

10) 위의 책, 같은 쪽.

11) 위의 책, 155쪽.

www.kci.go.kr

번째 고려사항인 '이용의 목적과 성질'에서 중요한 요소가 '변형적 이용(transformative use)'의 여부라는 점에서 문제가 발생한다. 그런데 2차적저작물작성권과 공정이용이 모두 의미를 가지려면 '2차적저작물의 작성행위로서의 변형'과 '공정이용으로서의 변형적 이용'의 차이가 무엇인지 밝히는 것이 필요하며, 이것이 이 논문의 연구목적이다.

위의 목적을 위하여 우선 미국 연방저작권법의 2차적저작물작성권과 공정이용에 관한 규정의 내용을 살펴본 후, 미국 연방법원에서의 '변형적 이용'의 개념을 정리한다. 그리고 미국 연방법원이 사용하는 '2차적저작물작성으로서의 변형'과 '공정이용으로서의 변형적 이용'은 결국 '표현형식의 변형'과 '이용목적의 변형'을 의미한다고 주장한다. 그리고 이 구분을 한국 저작권법에 도입할 때는 '사상 또는 감정의 변형' 기준을 사용할 것을 제안하는 순서로 논문을 전개한다.

II. 미국 연방저작권법의 2차적저작물작성권과 공정이용

1. 2차적저작물작성권 규정

미국 연방저작권법은 2차적저작물(derivative work)도 저작권의 보호대상이라고 규정하고(제103조(a)), "번역물, 편곡물, 극화물, 소설화물, 영화화물, 녹음물, 미술복제물, 요약물, 축약물, 또는 기타 어느 저작물을 개작, 변형(transform), 또는 각색한 형태와 같이, 하나 이상의 기존 저작물을 기초로 하여 작성된 저작물을 의미한다. 전체로서 원저작물을 나타내는 편집적 수정물, 주석물, 퇴고물, 또는 기타 수정물로 구성된 저작물은 '2차적저작물'이다."라고 2차적저작물을 정의하고 있다(제101조).[12] 그런데 미국연방저작권법의 2차적저작물의 정의규정에는 한국 저작권법과 마찬가지로 '변형'의

www.kci.go.kr

개념이 없으므로 공정이용의 '변형적 이용'과의 차이를 설명하는데 도움이 되지 못한다.[13] 따라서 다음에서는 공정이용규정의 내용을 살펴보고 공정이용의 첫 번째 고려요소인 '이용의 목적과 성질'의 공정성을 판단할 때의 '변형적 이용'의 개념을 알아본다.

2. 공정이용 규정

미국은 저작권침해에 대한 일반적 효력제한사유로서 '공정이용법리(fair use doctrine)'를 1976년 연방저작권법의 제107조에 규정하였다.[14] 제107조는 공정이용은 비평, 논평, 시사보도, 수업, 학문 또는 연구 등을 목적으로 하는 경우를 포함하며, 공정이용의 여부는 ① 이용의 목적과 성질, ② 이용된 저작물의 성질, ③ 이용된 부분의 양과 질이 저작물 전체에서 차지하는 비중, ④ 그 이용이 저작물의 잠재적 시장이나 가치에 미치는 영향을 고려하여 판단하여야 하고 작품이 미공표되었다고 하여 반드시 공정이용이 아니라고 할 수는 없다고 규정하고 있다.[15]

---

12) "A 'derivative work' is a work based upon one or more preexisting works, such as a translation, musical arrangement, dramatization, fictionalization, motion picture version, sound recording, art reproduction, abridgment, condensation, or any other form in which a work may be recast, transformed, or adapted. A work consisting of editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications which, as a whole, represent an original work of authorship, is a 'derivative work.'"

13) "However, this definition of a derivative work is not helpful for separating the wheat from the chaff in fair use cases." Okediji, 각주 7, at 126.

14) 공정이용법리의 연혁에 관하여는, 박준우, "공정이용의 기원과 의의: 퍼블릭도메인의 확보를 위한 공정이용규정의 제안", 「법학논총」 제29집 제2호, 전남대학교 법학연구소, 2009, ?쪽과 이대희, 각주 6, 345-346쪽 참조.

15) 17 U.S.C. § 107.

> Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting,

www.kci.go.kr

미국 연방법원이 제107조를 적용할 때 고려하는 네 개의 요소 중 첫 번째인 '이용의 목적과 성질'과 관련하여 '공정이용'의 인정에 유리한 방향으로 결론짓는 변수로서는 우선 동조의 전문에 규정된 "비평, 논평, 시사보도, 수업, 학문 또는 연구 등을 목적으로 하는 경우"가 있고 그 밖에 생산적 이용(productive use),[16] 변형적 이용(transformative use)[17] 등이 있다. 반대로 '이용의 목적과 성질'이 '공정이용'이 아니라는 결론의 변수로는 '상업적 이용(commercial use)'이 있다.[18]

---

teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include -

(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;

(2) the nature of the copyrighted work;

(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and

(4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.

The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.

16) "The distinction between "productive" and "unproductive" uses may be helpful in calibrating the balance, but it cannot be wholly determinative." Sony Corp. v. Universal City Studios, 104 S.Ct. 774, 795, n. 40 (1984)(이하 'Sony 사건'이라 한다.).

17) " ... the goal of copyright, to promote science and the arts, is generally furthered by the creation of transformative works. Such works thus lie at the heart of the fair use doctrine's ... " Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 114 S.Ct. 1164, 1171 (1994).

18) "Although not conclusive, the first factor requires that "the commercial or nonprofit character of an activity" be weighed in any fair use decision. If the Betamax were used to make copies for a commercial or profit-making purpose, such use would presumptively be unfair." 'Sony 사건,' 각주 16, at

www.kci.go.kr

III. '변형적 이용'의 개념

연방대법원이 '이용의 목적과 성질'의 공정이용 판단에 있어서 주요 변수로 인정한 '변형적 이용'은 Pierre Leval 판사가 1990년에 논문 "Toward a Fair Use Standard"에서 주장하였다.[19] 1991년에 'Kinko's 사건'에서 Constance Baker Motley 판사가 Leval 판사의 논문을 인용하며 "transformative"라는 용어가 처음으로 연방법원에서 사용되었으며,[20] 1994에 연방대법원은 'Campbell 사건'에서 "변형적 작품이 공정이용법리의 핵심"이라고 하기까지 이르렀다.[21][22] 다음에서는 Leval 판사의 논문과 미국 연방법원이 인정한 '변형적 이용'의 내용에 관하여 알아본다.

1. Leval 판사의 논문

'변형적 이용(transformative use)'의 단초를 제공한 Leval 판사는 그의 논문에서 공정이용으로 정당화될 수 있는 '이용의 목적과

792.

19) "I believe the answer to the question of justification turns primarily on whether, and to what extent, the challenged use is *transformative*." Pierre N. Leval, *Toward a Fair Use Standard*, 103 Harv. L. Rev. 1105, 1111 (1990).

20) Basic Books, Inc. v. Kinko's Graphics Corp., 758 F.Supp. 1522, 1530 (S.D.N.Y. 1991)(피고 복사점이 원고 출판사의 서적들에서 발췌한 부분을 모은 대학교재를 만들어 학생들에게 판매한 사건. 이하 'Kinko's 사건'이라 한다.). 법원은 Leval 판사의 논문 중 "A quotation of copyrighted material that merely repackages or republishes the original is unlikely to pass the test." 부분을 인용하며, Leval, 각주 19, at 1111, 피고의 작품은 단순한 'repackaging'에 불과하므로 transformative use가 아니라고 하였다. Id. at 1530.

21) 'Campbell 사건,' 각주 17, at 1171.

22) Matt Williams, *Recent Second Circuit Opinions Indicate That Google's Library Project is Not Transformative*, 25 Cardozo Arts & Ent. L.J. 303, 304-305, 313 (2007).

www.kci.go.kr

성질'은 "피고의 이용이 '공중의 계몽을 위한 창작을 장려'한다는 저작권법의 목적을 달성"하는 이용이며, 이것이 공정이용 사건의 핵심이라고 전제하였다.[23] 그리고 위의 저작권법의 목적을 달성하는 이용인가의 판단은 "피고의 이용이 변형적 이용인지의 여부와 변형의 정도"에 달려있다고 하였다.[24] Leval 판사에 의하면 '변형적 이용'은 '생산적 이용'임과 동시에 원고의 작품과는 '다른 방식 또는 다른 목적의 이용'이어야 한다.[25] 즉, 피고의 이용은 원고작품을 단순히 대체하는 것이 아닌 원고작품을 재료로 이용하여 새로운 가치를 부가하는 것, 예를 들면 새로운 정보·미감·통찰력·이해를 창작하는 방식으로 변형하는 것이 공정이용으로서의 '변형적 이용'이라고 하였다.[26]

2. 연방대법원과 연방항소법원의 판결

'Campbell 사건'에서 가수와 음반제작자인 피고들은 저작권자인 원고의 'Oh, Pretty Woman'의 패러디 랩곡(rap music)인 'Pretty Woman'을 발매하였다.[27] 연방대법원은 Leval 판사의 논문을 인용하면서 '변형적 작품의 창작'은 일반적으로 학문과 예술의 장려라는 저작권의 목적을 증진하며 저작권 안에서 숨 쉴 공간을 보장하는 공정이용법리의 핵심에 있다고 하였다.[28]

'Castle Rock 사건'에서[29] 피고는 원고작품에 대한 독자의 지식

23) "Does the use fulfill the objective of copyright law to stimulate creativity for public illumination? This question ... lies at the heart of the fair user's case." Leval, 각주 19, at 1111.

24) " ... whether, and to what extent, the challenged use if *transformative*." Id.

25) "The use must be productive and must employ the quoted matter in a different manner or for a different purpose from the original." Id.

26) " ... the secondary use adds value to the original – if the quoted matter is used as raw material, transformed in the creation of new information, new aesthetics, new insights and understandings ... " Id.

27) 'Campbell 사건,' 각주 17, at 1168-1169.

28) Id. at 1171.

www.kci.go.kr

을 테스트하는 작품은 “비평, 논평, 학술, 연구”에 해당하므로 변형적 이용이라고 주장하였으나, 제2연방항소법원은 Leval 판사의 논문을 인용한 ‘Campbell 사건’의 판결을 인용하며 피고작품은 단지 Seinfeld 시청자들을 위해서 Seinfeld를 재포장한 것에 불과하다며 변형적 이용이 아니라고 판단하였다.[30]

3. ‘2차적저작물작성으로서의 변형’과의 관계

‘Campbell 사건’에서 연방대법원은 특히 공정이용판단의 네 번째 요소인 ‘저작물의 잠재적 시장 또는 가치에 대한 영향’과 관련하여 다음과 같이 판결하였다.[31]

> … 비평은 2차적저작물 시장으로서 인정되지 아니하는 것이 원칙이다. 잠재적인 2차적저작물 시장은 원저작자들이 일반적으로 진출하거나 진출을 허락하는 시장만을 포함한다. 그러나 창작자들은 그들의 작품에 대한 비판적 견해 또는 풍자를 허락하지 아니할 것이므로 원저작물의 비평 또는 풍자적 이용은 잠재적인 라이센싱 시장에서 제외된다.

그러나 연방대법원은 피고의 작품이 비평의 요소와 2차적저작물의 요소를 모두 가지고 있는 경우에는 2차적저작물의 요소가 원고의 2차적저작물 시장에 미치는 잠재적 영향을 고려하여야 한다고 하였다.[32] 이 사건에서 피고작품은 패러디적 요소뿐만 아니라 랩곡

---

29) Castle Rock Entertainment v. Carol Publishing Group, 150 F.3d 132 (2d Cir. 1998)(원고는 유명 시트콤인 ‘Seinfeld’의 제작자이며 저작권자였고, 피고는 ‘Seinfeld’ 관한 지식을 묻는 “The Seinfeld Aptitude Test”라는 퀴즈책을 발행하였다. 이하 ‘Castle Rock 사건’이라 한다.).

30) Id. at 142-143.

31) ‘Campbell 사건,’ 각주 17, at 1178.

32) Id.

www.kci.go.kr

의 요소도 가지고 있으므로 피고작품이 원고의 2차적저작물 시장인 랩곡 시장(derivative market for rap music)에 미칠 영향도 고려하여야 한다고 하였다.[33] 그리고 일반적인 경우 피고의 이용이 상업적이면 원고작품의 시장에 대한 피해가 추정 또는 추론될 수 있지만, 피고의 이용이 변형적인 경우에는 피고의 이용이 상업적이라도 원고작품의 시장에 대한 피해가 쉽게 추론될 수 없다고 하였다.[34]

'Castle Rock 사건'에서 제2연방항소법원은 2차적저작물작성을 위한 '변형'과 공정이용 판단시의 '변형적 이용'의 차이 또는 관계에 관하여 언급하였다. 첫째, 법원은 공정이용의 "변형적 목적(transformative purpose)"을 충족하기 위하여 '원작의 변형'이 반드시 필요한 것은 아니라고 하였다.[35] 둘째, 그렇지만 '원작의 변형의 정도'는 '변형적 목적'을 판단하는데 고려사항이 될 수 있다고 하였다. 즉, 이 사건에서 원작의 변형이 거의 없는 점은 피고작품에 변형적 목적이 없다는 점의 입증에 도움이 된다고 하였다.[36] 이 작품에서 피고작품은 원고작품인 TV 시트콤 'Seinfeld'에 관한 지식을 묻는 퀴즈책이었는데, 법원은 피고작품에서 질문과 답의 형식으로 만들며 새로운 표현이 추가된 부분, 3지선다 또는 4지선다의 객관식 문제의 보기를 만든 점, 질문을 난이도에 따라 배치한 점 등을 피고가 원고작품에 가한 변형이라고 인정하였다.[37] 그러나 피고작품은 전체적으로 보아 원고작품으로부터 상당한 변경(alteration) 없이 직접적으로 이용한 것이며 이 정도의 변형은 과거에 동법원

33) Id.

34) Id. at 1177.

35) " ... a secondary work need not necessarily transform the original work's expression to have a transformative purpose, ... " 'Castle Rock 사건,' 각주 29, at 143.

36) " ... the fact that *The SAT* so minimally alters *Seinfeld*'s original expression ... is further evidence of *The SAT*'s lack of transformative purpose." Id.

37) Id.

www.kci.go.kr

이 공정이용을 인정하지 아니한 'Twin Peaks 사건'에서의 변형보다[38] 그 정도가 약하므로 변형적 이용을 인정할 수 없다고 하였다.[39] 마지막으로 법원은 2차적저작물 작성에 관한 '변형'과 '변형적' 이용과는 구별된다고 하였다. 즉, 2차적저작물은 원저작물을 새로운 표현형식으로 변형한 것이지만, 공정이용 작품과 다른 점은 원고작품의 표현을 이용함에 있어서 '변형적 목적'이 없는 것이라고 하였다.[40]

대부분의 공정이용 관련 판결이 2차적저작물과 공정이용에 있어서의 '변형'의 차이에 관하여 언급하지 아니한 반면, 'Castle Rock 사건'은 2차적저작물 작성에 있어서의 변형은 '표현형식의 변형(new mode of expression)'이지만 공정이용의 변형적 이용은 '목적의 변형(transformative purpose)'을 의미하는 것으로 구별하였다.[41] 또한 표현형식의 변형이 있어도 목적의 변형이 없을 수 있는 반면 표현형식의 변형이 없이도 목적의 변형이 있을 수 있다는 점을 언급한 것도 두 변형의 차이를 보다 명확히 하였다고 볼 수 있다. 그러나 구체적으로 어떠한 경우가 이에 해당하며 그 판단을 위한 기준과 고려사항을 구체적으로 제시하지 못 하였다는 한계가 있다.

IV. 미국 연방법원의 기준: '표현형식의 변형'과 '이용목적의 변형'의 구별

38) Twin Peaks Productions, Inc. v. Publications Intern., Ltd, 996 F.2d 1366 (2nd Cir. 1993)(피고작품은 원고의 TV 시트콤의 인기, 등장인물, 배우, 구성, 작가, 음악에 관하여 논의한 부분과 내용에 관한 퀴즈로 구성되어 있었는데 공정이용으로 인정받지 못 하였다. 이하 'Twin Peaks 사건'이라 한다.).

39) 'Castle Rock 사건,' 각주 29, at 143.

40) "Although derivative works that are subject to the author's copyright transform an original work into a new mode of presentation, such works-unlike works of fair use-take expression for purposes that are not "transformative."" Id.

41) R. Anthony Reese, *Transformativeness and the Derivative Work Right*, 31 Colum. J.L. & Arts 467, 472 (2008).

www.kci.go.kr

이 논문의 앞부분에서 피고작품의 2차적저작물의 침해여부가 쟁점인 판례에서 피고작품은 ①원고저작물의 복제물(실질적 개변이 없는 경우), ②2차적저작물(실질적 개변과 실질적 유사성이 있는 경우), ③별개의 저작물(실질적 유사성이 없는 경우)의 3가지 중 하나로 판단될 것이라고 하였다.[42] 'Castle Rock 사건'에서의 법원의 견해를 고려하면 2차적저작물의 공정이용 여부가 문제되는 사건에서는 피고작품은 ①원고저작물의 복제물이며 변형적 이용도 아닌 경우,[43] ②원고저작물의 복제물이지만 변형적 이용인 경우, ③2차적저작물이지만 변형적 이용이 아닌 경우, ④2차적저작물이며 변형적 이용인 경우, ⑤별개의 저작물인 경우로 분류할 수 있다.[44] 위의 5개의 경우 중 이 논문의 주제와 관련된 것은 세 번째와 네 번째 경우이다. 이들을 구별하는 기준으로서 'Castle Rock 사건'의 법원은 '표현형식의 변형만 있고 이용목적의 변형이 없는 것'은 세 번째 유형으로서 공정이용이 아니며, '표현형식의 변형과 함께 이용목적의 변형'도 있는 것은 네 번째 경우로서 2차적저작물의 공정이용이라고 하였다.

논문 저자 의견

그러므로 2차적저작물 작성이 공정이용의 인정을 위한 '변형적 이용'인가의 판단에 있어서 중요한 것은 단순한 표현형식의 변형인가 아니면 이용목적의 변형도 있었는가, 이용목적의 변형도 있었다

42) 각주 11에 해당하는 본문.

43) 공정이용의 여부가 문제되는 사건 중에는 영화 중 선정적인 부분 등 가족이 시청하기에 적합하지 아니한 부분을 저작권자의 허락 없이 미리 삭제하여 제작한 DVD가 공정이용으로서 2차적저작물작성권의 침해가 아닌가의 여부를 문제삼는 견해도 있다. Michael J. Madison, Rewriting Fair Use and the Future of Copyright Reform, 23 Cardozo Arts & Ent. L.J. 391, 394 (2005). 그러나 이는 2차적저작물작성권 침해의 문제나 공정이용의 문제가 아니라고 본다. 만약 피고가 내용의 일부분을 삭제한 DVD가 불법복제품이면 단순한 원저작물의 복제권의 침해이며, 정품이면 2차적저작물의 성립에 필요한 상당한 개변이 없는 경우로 보아 2차적저작물작성권의 침해가 아니라고 보아야 한다.

44) 별개의 저작물인 경우에는 침해자체가 부인되기 때문에 공정이용 판단의 고려사항으로서 변형적 이용의 여부가 의미가 없을 것이다.

www.kci.go.kr

면 어느 정도 있었는가의 판단일 것이다. 그러나 이는 쉬운 작업이 아니다. 첫째, 피고가 원고작품을 변형한 것이 표현형식인지 아니면 이용목적인지가 불분명한 경우도 있을 것이다. 'Castle Rock 사건'에서와 같이 법원에서 원고는 표현형식의 변형을 주장할 것이며 피고는 이용목적의 변형을 주장할 것이다. 문제는 표현형식과 이용목적의 변형의 경계가 불분명하다는 것이다. 'Castle Rock 사건'의 법원이 밝혔듯이 "표현형식의 변형이 거의 없는 것은 이용목적의 변형이 없다는 것의 증거"가 될 수 있기 때문이다.[45]

이러한 판단을 위하여 법원이 우선 하여야 할 작업은 불명확한 부분(grey zone)을 줄여가는 것이다. 이는 '이용목적의 변형이 명백한 경우'와 반대로 '이용목적의 변형이 아닌 표현형식의 변형이 명백한 경우'를 유형화하는 작업을 의미한다. Leval 판사는 그의 논문에서 '이용목적의 변형'의 예로 비평, 원작자의 성향의 공개, 사실의 증명, 원작품의 사상을 옹호 또는 공격할 목적으로 원작품의 내용을 요약하는 것, 패러디, 상징화, 미학적 선언 등을 열거하였다.[46]

반면 '이용목적의 변형이 아닌 표현형식의 변형이 명백한 경우'로서는 전통적으로 원저작자의 2차적저작물 시장으로 인정된 경우로서 원저작물의 번역·편곡·각색·영상제작 등의 예가 있다. 이들의 공통점은 원저작물을 다른 매체 또는 표현수단으로 이용하려는 수요에 부응하기 위한 표현형식의 변형이 필요하다는 점이다. 따라서 이 경우에 원저작물에 가하는 변형은 원저작물의 표현형식을 다른 매체 기타 표현수단에 맞추기 위한 표현형식의 변형에 불과하며 이용목적의 변형은 없다.

---

45) 'Castle Rock 사건,' 각주 29, at 143.

46) "Transformative uses may include criticizing the quoted work, exposing the character of the original author, proving a fact, or summarizing an idea argued in the original in order to defend or rebut it. They also may include parody, symbolism, aesthetic declarations, and innumerable other uses." Leval, 각주 19, at 1111.

www.kci.go.kr

V. '표현된 사상 또는 감정의 변형' 기준의 제안

엄격히는 " 변형적 이용 "에 대한 것이기 때문에 잘못된 표현이지만, 실

'이용목적의 변형'인지 단순한 '표현형식의 변형'에 불과한 것인지의 판단기준으로서 우리 저작권법 제2조의 '저작물'의 정의를 이용할 수도 있을 것이다. 동조 제1호는 '저작물'을 "인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물"로 정의하고 있다. 위에서 설명한 바와 같이 Leval 판사의 논문에 따르면 '이용목적의 변형'이란 "원고작품을 재료로 이용하여 새로운 가치를 부가하는 것"이다.[47] 그런데 피고가 원고작품에 부가하는 새로운 가치로 볼 수 있는 것 중 가장 최소한의 범위는 원고와는 다른 피고가 새롭게 부가한 '사상 또는 감정'일 것이다. 따라서 피고작품이 원저작물과는 '다른 사상 또는 감정을 표현'한 경우, 즉 원저작물과는 '다른 사상 또는 감정을 표현'하기 위하여 원저작물을 재료로 이용한 경우가 '이용목적의 변형'을 인정할 수 있는 최소한의 범위라고 본다. Leval 판사가 그의 논문에서 이용목적의 변형의 예로 열거한 경우도 결국 원저작물과는 다른 사상과 감정을 표현한 경우라고 본다. 그리고 전통적으로 (또는 법률의 규정에 의하여) 원저작물의 2차적저작물로 인정되는 번역·편곡·각색·영상제작 등은 원저작물과 동일 또는 유사한 사상이나 감정을 다른 형식으로 표현한 것으로서 '표현형식의 변형'만 있을 뿐이고 '이용목적의 변형'은 없는 경우라고 할 수 있다.

'Castle Rock 사건'에서 피고작품인 원저작물에 관한 퀴즈책이 원고의 저작물인 시트콤과는 다른 사상이나 감정을 표현하고 있었는지의 여부를 살펴보면, 피고작품은 원저작물의 내용의 일부를 그대로 전달하고 있으며 그 표현형식이 문답식으로 변형된 것 이외에 특별히 원저작물과 다른 사상 또는 감정을 전달하고 있다고는 볼 수 없다.[48]

---

47) Id.

48) 주의할 점은 'Castle Rock 사건'에서 피고작품이 원고작품과는 다른 사상과 감정을 표현하지 아니한다는 사실이 필연적으로 '이용목적의 변형이 없다'거나 '공정이용이 아니다'라는 결론으로 이어지는 것은 아니라는 점이다. 왜냐하면 본문에서 필자가 주장한 바와 같이 '원저작물과는 다른 사상과 감정의 표현'은

www.kci.go.kr

'다른 사상이나 감정의 표현' 기준은 특히 언론·출판·표현·예술의 자유라는 헌법적 가치의 실현과 관련하여서도 의미를 가진다. 일반적으로 원저작자들은 타인이 자신의 저작물을 이용하여 다른 사상이나 가치를 표현하는 것을 원하지 아니할 것이며 원저작자 본인이 원저작물을 통하여 표현하였던 것과 다른 사상이나 감정을 2차적저작물을 통하여 표현하는 것도 쉽지 아니할 것이다. 따라서 'Castle Rock 사건'의 법원이 패러디에 관하여 설명한 것과 같이 이 경우에는 원저작자가 피고작품과 같은 종류의 2차적저작물 시장에 직접 진출하거나 진출을 허락하려는 의도가 인정되기 힘들다고 볼 수 있다.[49] 그럼에도 불구하고 피고가 원저작물을 이용하여 원저작물과는 다른 사상 또는 감정을 표현하는 것을 금지한다면, 이는 헌법상 보장된 언론·출판·표현·예술의 자유를 아무런 정당한 근거 없이 제한하는 데에 저작권법이 이용되는 결과가 된다.[50][51]

이용목적의 변형을 인정할 수 있는 '최소범위'이며 '최대범위'가 아니기 때문이다. 또한 '이용목적의 변형'도 공정이용의 첫 번째 고려요소인 '이용의 목적과 성질'을 판단하는 하나의 비중이 큰 요소에 불과하며 '공정한 이용의 목적과 성질의 인정'과 필요충분조건의 관계에 있지 아니하기 때문이다. "The consequence of this emphasis [on transformative use] is that nontransformative copying, including plain old photocopying even in educational or scientific contexts, begins to look unfair." Rebecca Tushnet, *Copy This Essay: How Fair Use Doctrine Harms Free Speech and How Copying Serves It*, 114 Yale L.J. 535, 556 (2004).

49) 굳이 패러디의 경우가 아니라도 2차적저작물작성권은 일반적으로 2차적저작물의 작성에 관한 강한 인센티브를 주지 못 한다고 한다. Stewart E. Sterk, *Rhetoric and Reality in Copyright Law*, 94 Mich. L. Rev. 1197, 1215-1216 (1996).

50) 그러나 원저작물과는 다른 사상과 감정이 표현된 피고작품만을 이용목적이 변형된 경우로서 공정이용으로 인정한다면 헌법상 보장된 언론·출판·표현·예술의 자유를 오히려 제한하는 결과가 될 수도 있음을 주의하여야 한다.

51) 주목할 만한 견해로는 '이용목적의 변형' 여부를 판단할 때 '피고의 의도'가 아닌 피고작품에 대한 독자의 해석에 초점을 두어야 한다는 견해가 있다. Laura A. Heymann, *Everything Is Transformative: Fair Use and Reader Response*, 31 Colum. J.L. & Arts 445, 456 (2008). 이 견해에 의하면 독자들이 피고작품을 비판적으로 받아들이는지의 여부에 관한 증거 또는 이러한 증거가 없는 경우에는 법원이 합리적인 독자(reasonable reader)의 입장에서 변형적 이

www.kci.go.kr

VI. 결론

만약 공정이용법리가 한국 저작권법에 도입된다면, 그 규정방식과 해석론에 관한 논의가 지금보다 더욱 활발하게 진행될 것이다. 논의의 대상은 첫째, 문화의 향상발전을 궁극적인 목적으로 하여 저작권자와 저작물 이용자의 이익 사이의 균형 잡힌 입법론 및 해석론의 개발, 둘째, 권리자와 이용자에게 예측가능성을 줄 수 있는 해석론과 가이드라인의 개발, 셋째, 저작권법의 다른 규정과의 일관성 유지를 위한 입법론과 해석론의 개발 등이다. 그리고 이 논의를 진행함에 있어서 우리법 체계에 맞는 기준을 개발하여 적용사례를 축적하는 것이 중요하다. 이 논문은 이 중 세 번째 주제와 관련하여 특히 2차적저작물작성으로서의 '변형'과 공정이용으로서의 '변형'의 차이에 관하여 미국 연방법원의 견해를 정리하고 우리 저작권법의 해석을 위한 '사상 또는 감정의 변형' 기준을 제안하였다. 공정이용으로서의 '변형적 이용'과 관련하여 간과하면 아니 되는 사항을 강조하면 다음과 같다.

첫째, 변형적 이용, 즉 이용목적의 변형은 공정이용의 인정에 있어서 중요한 변수이지만 이용목적의 변형이 인정되는 경우에만 공정이용이 인정될 수 있는 것은 아니다.[52]

둘째, 이 논문에서 제안한 '사상 또는 감정의 변형' 역시 '변형적 이용'이 인정될 수 있는 최소한의 범위이며, '사상 또는 감정의 변

용의 여부를 판단한다. Id. at 456-457.

52) 예를 들면, 변형적 이용목적의 고려 이외에도 피고의 원저작물 이용행위로 인한 원저작자의 손해, 원저작물 생산의 질적·양적 감소, 피고작품의 창작성의 정도, 정보접근이나 교사들의 수업준비를 용이하게 하는지의 여부, 원저작자가 가격차별을 하는지의 여부 등도 법원이 공정이용의 판단시에 고려하여야 한다고 하는 견해가 있다. William W. III Fisher, *Reconstructing the Fair Use Doctrine*, 101 Harv. L. Rev. 1659, 1782 (1988). 공정이용 판단의 요소로서 시장에 대한 영향을 고려하여야 한다는 주장에 관하여는 Lydia Pallas Loren, *Redefining the Market Failure Approach to Fair Use in an Era of Copyright Permission Systems*, 5 J. Intell. Prop. L. 1 (1997) 참조.

www.kci.go.kr

형'이 없는 경우에도 '변형적 이용'이 인정될 수 있는 경우는 있다.

마지막으로 미국의 공정이용법리의 역사를 통하여 얻을 수 있는 중요한 교훈이 있다. 법원·입법자 또는 연구자는 '변형적 이용목적' 등을 포함한 대부분의 고려사항들을 공정이용의 판단시에 고려하여야 할 여러 가지의 요건 중 하나로서만 언급하였다. 그럼에도 불구하고 저작물의 생산자 또는 이용자들이 그들의 이익을 위하여 마치 공정이용 판단의 필요조건 또는 충분조건으로서 인정된 것처럼 왜곡하는지의 여부를 철저히 감시하고 경계하여야 한다.[53]

53) 다음의 의견이 현재 '변형적 이용'이 공정이용의 판단에 있어서 가지는 위치를 정확히 표현했다고 본다: " ... if it is not transformative, the odds that it is a fair use are relatively low. If it is transformative, you may have leapt over one hurdle but you've still got some other tests to meet." Symposium: Panel III, Fair Use: Its Application, Limitations and Future, 17 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 1017, 1078 (2007).

www.kci.go.kr

참고문헌

1. 국내문헌

오승종, 「저작권법」, 박영사, 2007.

김원오, “패러디 항변을 둘러싼 저작권법상 쟁점과 과제”, 「안암법학」 제14호, 안암법학회, 2002.

박준우, “공정이용의 기원과 의의: 퍼블릭도메인의 확보를 위한 공정이용규정의 제안”, 「법학논총」 제29집 제2호, 전남대학교 법학연구소, 2009.

우지숙, “UCC 창작물에 대한 저작권법 적용의 쟁점 및 미국 패러디 관련 판례의 시사점: 변형적 이용(transformative use) 개념의 도입을 제안함”, 「계간저작권」 제21권 제3호, 저작권위원회, 2008.

이대희, “저작권법상의 공정이용의 법리에 관한 비교법적 연구”, 「경영법률」 제10권, 한국경영법률학회, 2000.

함석천, “패러디, 지적재산권과 표현의 자유”, 「저스티스」 통권 제91호, 한국법학회, 2006.

2. 외국문헌

William W. III Fisher, Reconstructing the Fair Use Doctrine, 101 Harv. L. Rev. 1659 (1988).

Paul Goldstein, Fair Use in Context, 31 Colum. J.L. & Arts 433 (2008).

Laura A. Heymann, Everything Is Transformative: Fair Use and Reader Response, 31 Colum. J.L. & Arts 445 (2008).

Pierre N. Leval, Toward a Fair Use Standard, 103 Harv. L. Rev. 1105 (1990).

Ruth Okediji, Givers, Takes, and Other Kinds of Users: A Fair

www.kci.go.kr

Use Doctrine for Cyberspace, 53 Fla. L. Rev. 107 (2001).

Lydia Pallas Loren, Redefining the Market Failure Approach to Fair Use in an Era of Copyright Permission Systems, 5 J. Intell. Prop. L. 1 (1997).

Michael J. Madison, Rewriting Fair Use and the Future of Copyright Reform, 23 Cardozo Arts & Ent. L.J. 391 (2005).

R. Anthony Reese, Transformativeness and the Derivative Work Right, 31 Colum. J.L. & Arts 467 (2008).

Stewart E. Sterk, Rhetoric and Reality in Copyright Law, 94 Mich. L. Rev. 1197 (1996).

Symposium: Panel III, Fair Use: Its Application, Limitations and Future, 17 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 1017 (2007).

Rebecca Tushnet, Copy This Essay: How Fair Use Doctrine Harms Free Speech and How Copying Serves It, 114 Yale L.J. 535 (2004).

Matt Williams, Recent Second Circuit Opinions Indicate That Google's Library Project is Not Transformative, 25 Cardozo Arts & Ent. L.J. 303 (2007).

Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 114 S.Ct. 1164 (1994).

Sony Corp. v. Universal City Studios, 104 S.Ct. 774 (1984).

Castle Rock Entertainment v. Carol Publishing Group, 150 F.3d 132 (2d Cir. 1998).

Twin Peaks Productions, Inc. v. Publications Intern., Ltd, 996 F.2d 1366 (2nd Cir. 1993).

Basic Books, Inc. v. Kinko's Graphics Corp., 758 F.Supp. 1522 (S.D.N.Y. 1991).

www.kci.go.kr

<Abstract>

Transformation and Transformative Use of Copyrighted Work

-New Mode of Expression and Transformative Purpose-

Junu Park

The purpose of this article is to find out the test for distinguishing "transformative use" as a fair use of a copyrighted work from mere "transformation" as a preparation for a derivative work of the work. The test for the distinction is necessary because over- or under-interpretation of the terms might be able to make meaningless either fair use or right to prepare a derivative work, which, in turn, might result in breaking the balance between the dissemination and concentration of copyrighted information.

This article tries to achieve the goal by analyzing federal supreme court and circuit court cases. One second circuit case, Castle Rock Entertainment v. Carol Publishing Group, mentioned the difference between "transforming an original work into a derivative work" and "using an original work for a transformative purpose." The court said that mere transformation does not reach transformative use, while transformative use does not require transformation. Thus, mere transformation means altering manners or modes of expression, while transformative use means altering the purpose of the use.

This article also proposes another test for distinguishing transformative use from mere transformation for the interpretation of the future fair use provision of Korea Copyright

www.kci.go.kr

Act. This article proposes that the minimum range of transformative use can be the use of an original work that shows different ideas or feelings from those of the original work.

≪주제어 : Key words≫

공정이용, 변형적 이용, 2차적저작물, 변형, 표현형식의 변형, 변형적 목적

fair use, transformative use, derivative work, transformation, transformation in manner, transformative purpose

※ 게재논문심사정보
논문접수일 : 2009년 10월 28일
심사개시일 : 2009년 11월 10일
게재확정일 : 2009년 12월 11일

www.kci.go.kr